DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 13-2022-MEVGP-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Per Ingenieros Consultores Ejecutores S.A.C.

Demandado : Municipalidad Distrital de Kimbiri.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Mario Eduardo Vicente González Peralta – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 25 de agosto de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 20 de setiembre de 2022.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 08 de agosto de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Arbitraje Institucional seguido entre

PER INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.

(DEMANDANTE)

MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE KIMBIRI

(DEMANDADO)

EXPEDIENTE: № 13-22-CECARD/AYA

LAUDO ARBITRAL

ÁRBITRO ÚNICO

MARIO EDUARDO VICENTE GONZÁLES PERALTA – ÁRBITRO

SECRETARIA ARBITRAL

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI

FECHA:

Ayacucho, 08 de agosto del 2023

Número de Expediente CECARD: 13-2022-MEVGP-CA-CECARD/AYA

Demandante: PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. (En adelante, el Contratista o el Demandante).

Demandado: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI (En adelante, la Entidad, Municipalidad o el Demandado).

Contrato: № 064-2021-MDK-GM/LOG **"**Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Través de Pistas y Veredas en los Sectores de Huarmamayo, Villa Pasarella y Agua Viva de la Capital del Distrito de Kimbiri, La Convención – Cusco". (En adelante, el Contrato).

Monto del Contrato: S/ 103,348.32

Cuantía de la Controversia: S/ 103,348.32

Tipo y Número de Proceso de Selección: Adjudicación Simplificada № 47-2021-MDK/CS-1

Árbitro Único: Mario Eduardo Vicente González Peralta.

Secretaria Arbitral: Raida Yovana Flores Cayllahui

Monto de los honorarios del Árbitro Único: S/ 4,227.01

Monto de los honorarios de la Secretaría Arbitral: S/ 3,200.22

Fecha de emisión del laudo: 08 de agosto del 2023

(Unanimidad/Mayoría): Unanimidad

№ de Folios: 39

Pretensiones (controversias relacionadas a las siguientes materias):

- ☐ Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato.
- ☑ Resolución del contrato.
- ☐ Ampliación del plazo contractual.
- ☐ Defectos o vicios ocultos.
- ☐ Formulación, aprobación o valorización de metrados.
- ☐ Recepción y conformidad.
- ☐ Liquidación y pago.
- ☐ Mayores gastos generales.
- ☑ Indemnización por daños y perjuicios.
- ☐ Enriquecimiento sin causa.
- ☐ Adicionales y reducciones.
- ☐ Adelantos.
- ☐ Penalidades.
- ☐ Ejecución de garantías.
- ☐ Devolución de garantías.

RESOLUCIÓN № 16

Ayacucho, 08 de agosto del 2023

VISTOS:

I. INDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

Partes:

- En calidad de Demandante: PER & Ingenieros Consultores Ejecutores S.A.C. Representado por Percy López Flores (En adelante, el Contratista o el Demandante).
- En calidad de Demandado: Municipalidad Distrital de Kimbiri, representado por Iván Rafael Chimpay Prado en su calidad de Procurador Público Municipal (En adelante, la Entidad, Municipalidad o el Demandado).

II. ANTECEDENTES Y CONVENIO ARBITRAL

1. Con fecha 14 de diciembre del 2021 las partes en conflicto suscribieron el contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG **"**Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Través de Pistas y Veredas en los Sectores de Huarmamayo, Villa Pasarella y Agua Viva de la Capital del Distrito de Kimbiri, La Convención – Cusco", siendo el monto contractual de S/. 103,348.32, importe que incluía impuestos y todo concepto que incida en el contrato, se desarrolló bajo la modalidad mixta de tarifas y suma alzada. Siendo su plazo de ejecución de 210 días calendario.
2. La Cláusula Décimo Tercera contenía el convenio arbitral el cual indicaba:

> **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
>
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

III. DESIGNACIÓN E INSTALACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICOUNIPERSONAL

3. Generada la controversia, ambas partes determinaron que el presente proceso arbitral se realice bajo la administración y regulación del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, (en adelante CECARD o el Centro de Arbitraje).

4. En atención a ello, mediante carta № 199-2022-SG-CA-CECARD/AYA de fecha 08 de setiembre del 2022 el CERCARD comunicó al que suscribe la designación como Árbitro Único, la que fuera aceptada con carta s/n de la misma fecha, nombramiento que una vez puesto en conocimiento de las partes no fue materia de recusación u oposición, consintiendo así con ella, asumiendo plena competencia para resolver el fondo de la controversia.

IV. TIPO DE ARBITRAJE, REGLAS PROCESALES Y LEY APLICABLE AL FONDO DE LA CON TROVERSIA

5. En virtud al Convenio Arbitral contenido en la cláusula décima séptima del CONTRATO y al acuerdo de las partes manifestado mediante escrito de solicitud de arbitraje y contestación de solicitud de arbitraje, el presente arbitraje será un ARBITRAJE INSTITUCIONAL, NACIONAL Y DE DERECHO.

6. En consecuencia, las partes se sometieron expresamente a la administración del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas- CECARD, a sus Reglamentos y Lineamientos.

V. LEY APLICABLE

7. Las normas aplicables al presente proceso son las siguientes:

   a. Reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.

   b. Ley de Contrataciones del Estado, Ley № 30225 (en adelante Ley de Contrataciones o LCE)

   c. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo № 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo № 162-2021-EF (en adelante el Reglamento de la Ley o el Reglamento.)

   d. Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, Decreto Legislativo №1071 (en adelante la Ley de Arbitraje)

   e. Los principios, usos y costumbres en materia arbitral y contractual, cuando corresponda su aplicación a criterio del Árbitro Único

   f. La aplicación supletoria de las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda.

VI. RESUMEN PROCEDIMENTAL DEL ARBITRAJE

8. Con fecha 20 de octubre del 2022, y dentro del plazo correspondiente, PER & Ingenieros Consultores Ejecutores S.A.C. presentó su demanda, postulando sus pretensiones y exponiendo los fundamentos de hecho y derecho que las sustentan, acompañando las pruebas que estimaron a su derecho, la que fue admitida a trámite y puesta a conocimiento de su contraria. La Municipalidad Distrital de Kimbiri contestó la demanda el 15 de noviembre del 2022, igualmente dentro del plazo establecido, oportunidad en la que argumento lo que estimó a su derecho de defensa, adjuntando los medios probatorios que consideró apropiados.

9. Teniendo en cuenta lo anterior y todo lo actuado, el Árbitro Único considera que en el presente arbitraje se ha concedido a ambas partes la oportunidad necesaria para plantear su posición en relación con la controversia, es decir, el derecho a la igualdad que asiste a las partes se ha garantizado, por cuanto las mismas han tenido el mismo plazo de tiempo a fin de presentar sus pretensiones y medios probatorios al presente proceso.

Costos Arbitrales

10. En Resolución № 1 de fecha 20 de setiembre del 2022, se establecieron las reglas arbitrales, dentro de las cuales se fijaron los gastos arbitrales, los que se determinaron en S/. 4,227.01 como honorarios del Árbitro Único y S/. 3,200.22 por concepto de gastos administrativos; disponiendo que sean de cargo de ambas partes en proporciones iguales, sin embargo, la totalidad de ellos fue asumido por el Demandante, cuyo pago fue acreditado mediante Resolución № 7 del 05 de enero del 2023 y № 8 de fecha 08 de marzo del 2023.

Determinación de puntos controvertidos, admisión y actuación de pruebas;

11. Culminada la etapa postulatoria y no habiéndose presentado medios de defensa, mediante Resolución 8 del 08 de marzo del 2023 se fijaron los puntos controvertidos, los que quedaron fijados como sigue:

    PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

    Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal declare la invalidez y/o ineficacia de la Resolución de Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, efectuado por la Municipalidad Distrital de Kimbiri, a través de la Carta Notarial № 027-2022-MDK/GM

    SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

    Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal declare la validez y eficacia de la resolución del Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, efectuado por la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C, mediante Carta Notarial № 003-2022-PICE.SAC/GG

TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Kimbiri, el pago por concepto de indemnización de daños y perjuicios, a favor de la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C

CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Kimbiri pagar las costas y costos asumidos por la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C en el presente proceso arbitral.

12. En dicha oportunidad se dejó constancia que los puntos en controversia señalados tienen naturaleza referencial y podrían ser ajustadas o reformuladas por el Árbitro Único si a su juicio ello resultara conveniente para facilitar la resolución de la controversia, sin que el orden empleado, el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de algún tipo.

13. Igualmente se dejó establecido que el Árbitro Único se reservaba el derecho de analizar las materias de pronunciamiento en el orden que considere más conveniente a los fines de resolver la controversia y no necesariamente en el orden previamente establecido, y también de pronunciarse sobre cualquiera de las cuestiones conexas o accesorias al fondo de la controversia que se hayan promovido durante las actuaciones arbitrales, siempre que respecto de éstas se haya respetado estrictamente el derecho de defensa de las partes, incluyendo, pero no limitándose el derecho a contradecir, probar y ser oídos, en igualdad de condiciones.

14. Finalmente se determinó que si al momento de referirse a alguna cuestión materia de pronunciamiento, el Árbitro Único llega a determinar que carece de objeto pronunciarse sobre otras cuestiones con las que ésta guarde vinculación, podrá omitir referirse a estas otras, expresando las razones de tal omisión. Decisión que no fue objeto de oposición alguna, quedando consentida.

<u>Audiencia Única;</u>

15. Mediante Resolución № 09, de fecha 24 de marzo del 2023 se resolvió, entre otros puntos, citar a las partes a Audiencia virtual que fue programada para el día 10 de abril del 2023; la misma que se llevó a cabo con participación de las partes quienes expusieron lo que estimaron a su derecho, asimismo, tuvieron la posibilidad de hacer uso de la réplica y dúplica durante la audiencia por el mismo espacio y respondiendo las preguntas que el árbitro Único estimo necesarias.

Presentación de alegatos y Audiencia de Informes Orales;

16. De conformidad con lo establecido en el Artículo 45 del Reglamento de Arbitraje, con fecha 05 de junio del 2023 se emitió la Resolución 13 dando por concluida la etapa probatoria y otorgando a las partes plazo para que presenten sus alegatos y, si lo estimasen conveniente, soliciten el uso de la palabra.

17. En ese contexto, con fecha 14 de junio del 2023, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, mediante la cual ambas partes cumplieron con realizar una exposición sobre sus posiciones, apreciaciones y aclaraciones que consideren pertinentes; oportunidad en la que se otorgó a las partes plazo para que presenten sus conclusiones finales.

Fijación de plazo para laudar;

18. Dado el estado de las actuaciones arbitrales y considerando que las partes han tenido una oportunidad razonable para presentar y probar sus posiciones sobre las materias que han de ser objeto de decisión en un laudo, y en mérito al artículo 47 del Reglamento Arbitral, se emitió la Resolución, 14 del 20 de junio del 2023, que dispuso el cierre de las actuaciones y fijó plazo para laudar, plazo que fue prorrogado mediante Resolución № 15 de fecha 04 de agosto del 2023

VI. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

19. Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo siguiente:

    (i) La designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las disposiciones establecidas en el convenio arbitral y el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje CECARD.

    (ii) Que en ninguna de las partes impugnaron la designación del Árbitro Único;

    (iii) Que las partes no impugnaron las reglas procesales fijadas para el presente proceso;

    (iv) Que las partes tuvieron plena oportunidad para plantear y sustentar sus posiciones, ofrecer y actuar todos sus medios probatorios; así como tuvieron la facultad de presentar alegatos e, inclusive, informar oralmente mediante Audiencia de Ilustración y Audiencia de informes orales, desarrollándose las actuaciones arbitrales respetando las garantías de audiencia bilateral, contradicción y trato igualitario a las partes;

    (v) Que, en el estudio, análisis, apreciación y razonamiento del caso, el Árbitro Único ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones expuestas, así como todos los medios probatorios aprobados y admitidos, haciendo un

análisis y valorización en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión;

(vi) Que siendo un arbitraje de Derecho, corresponde al Árbitro Único pronunciarse respecto de las pretensiones formuladas, teniendo en cuenta el mérito de la prueba aportada al proceso para determinar en base a su valoración conjunta, las consecuencias jurídicas que de acuerdo al Derecho se derivan para las partes, correspondiendo la carga de la prueba a quién alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos;

(vii) Que, en relación a las pruebas aportadas al presente proceso arbitral, por aplicación del Principio de Comunidad o Adquisición de la Prueba, las pruebas ofrecidas y admitidas en el proceso pertenecen al arbitraje pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció; y,

(viii) Que, el Árbitro Único ha procedido a laudar dentro del plazo establecido.

20. Asimismo, al emitir el presente Laudo Arbitral, el Árbitro Único declara que ha valorado la totalidad de los medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el arbitraje, así como las alegaciones formuladas por las partes referidas a la materia controvertida. De este modo, la no indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las partes, no implica bajo ninguna circunstancia que determinado medio probatorio o determinado hecho no haya sido valorado.

21. Por lo expuesto, el Árbitro Único deja establecido que en aquellos supuestos en los que este Laudo Arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que, a su criterio, tuviese respecto de la controversia materia de análisis.

22. En tal sentido, el Árbitro Único reitera que ha merituado los medios probatorios que obran en el expediente y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje ha realizado una libre y razonado valoración de los mismos; en consecuencia, no sería correcto afirmar que el hecho de no pronunciarse concretamente sobre un medio probatorio determinando implica que no ha sido debidamente valorado; sobre todo, tomando en consideración que el estándar de prueba aplicable al ordenamiento jurídico peruano es el de la “libre valoración de la

prueba", el cual –como es sabido– reposa sobre los siguientes elementos: la valoración conjunta y la apreciación razonada.

23. Conforme a la doctrina, la valoración conjunta no exige al juzgador –en el caso concreto, al Árbitro Único– que se pronuncie sobre todos y cada uno de los medios probatorios aportados por las partes de forma aislada. La exigencia se limita a realizar un juicio crítico del conjunto de los medios probatorios aportados al proceso.

24. Por su parte, la apreciación razonada determina el nivel de motivación del árbitro en la valoración de los medios probatorios, de forma tal que se exige al juzgador que motive y se pronuncie expresamente respecto de aquellos medios probatorios esenciales que sustentan su decisión.

25. De ese modo, la libre valoración de la prueba se encuentra vinculada con el alcance que debe tener la motivación, con la limitación de que no debe haber un pronunciamiento específico sobre todos los medios probatorios.

26. Aunado a ello, se deberá tener en consideración que la enumeración de los puntos controvertidos sobre los que se pronunciará el Árbitro Único es meramente ilustrativa, constituyendo una pauta referencial, la cual no limita el orden del análisis que realizará el Árbitro Único respecto de la controversia y las pretensiones planteadas en el Arbitraje.

27. De acuerdo con lo establecido en la Audiencia Única, corresponde al Árbitro Único pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta el mérito de la prueba, así como a los fundamentos expuestos por cada parte, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de lo que haya sido probado o no, en el marco del arbitraje.

28. Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a ellos.

29. Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación con las pruebas aportadas al arbitraje que, en aplicación del Principio de *"Comunidad o Adquisición de la Prueba"*, las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que las ofreció.

30. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

> *"… la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para*

determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó"[1].

31. En este contexto, el Árbitro Único tiene en cuenta el Principio *Onus Probandi Incumbit actori*, que consiste en que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, correspondiendo al Árbitro la valoración conjunta, lógica, crítica y razonada de todos los medios probatorios que tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes.

32. En igual sentido, el artículo 39 de la Ley de Arbitraje señala que "Las partes, al plantear su demanda (..) deberán aportar todos los documentos que consideren pertinentes. De igual forma, el artículo 34, numeral 3) del Reglamento del Centro Arbitral establece que "Las partes ofrecen y, en su caso, presentan con su demanda, su contestación, así como con su eventual reconvención y su respectiva contestación, los documentos y otras pruebas en las que sustenten sus pretensiones y defensas."

33. En suma, el derecho a la prueba implica la responsabilidad de las partes a efectos de generar certeza en el juzgador respecto a sus pretensiones. En efecto, la labor del Árbitro Único debe implicar el análisis de los argumentos de las partes junto con cada uno de los medios probatorios presentados; sin embargo, si las posiciones de las partes no se sustentan en medios probatorios, entonces estas no pueden ser amparadas, pues significarían un alejamiento al Estado de Derecho y afectación a los derechos de la contraparte.

VII. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal declare la invalidez y/o ineficacia de la Resolución de Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, efectuado por la Municipalidad Distrital de Kimbiri, a través de la Carta Notarial № 027-2022-MDK/GM.

A continuación, se reseñan los principales fundamentos de hecho y de derecho a los que hacen referencia las partes respecto a presente punto controvertido

<u>Posición del Demandante:</u>

34. Señala el Demandante que luego de ganar la Buena Pro del Procedimiento de Selección por Adjudicación Simplificada № 47-2021-MDK/CS-1, el 14 de diciembre

[1] TARAMONA H., José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas 1994, pág. 35.

del 2021 suscribió con la Entidad el Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, cuyo objeto consistió en su contratación para la supervisión de obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Través de Pistas y Veredas en los Sectores de Huarmamayo, Villa Pasarella y Agua Viva de la Capital del Distrito de Kimbiri, La Convención – Cusco", por el monto de S/. 103,348.32, contrato que se desarrollaba bajo el sistema de esquema mixto de tarifas y suma alzada.

35. Agrega que mediante Carta Notarial № 007-2022-MDK/GM, de fecha 16 de mayo de 2022, con asunto "Cumplimiento de obligación contractual de su oferta técnica", la municipalidad les requiere, *"… el cumplimiento de las obligaciones esenciales de su oferta y de su responsabilidad derivado del Contrato № 064- 2021-MDK-GM/LOG, bajo apercibimiento de resolución"*,

36. Continúa el Demandante indicando que en el documento se consignó como referencia el Informe № 685-2022-MDK/GM/OGSEI/MPM-D, más no detalló de manera clara y motivada cuales fueron las obligaciones incumplidas por esta parte, ya que en su página 3, solamente se ocupa en describir las funciones del supervisor, no detallándose si éstas fueron incumplidas de manera total o parcial.

37. A pesar de ello el Contratista manifiesta que, si realizó los descargos respectivos, en donde dejan en claro que han cumplido con sus obligaciones contractuales, ya que cuenta de manera directa y permanente con el personal clave ofertado, lo que se prueba con las múltiples anotaciones en el cuaderno de obra realizadas por el supervisor, cuyas copias adjuntan.

38. No obstante, ello la Entidad les notificó con la Carta Notarial № 027-2022-MDK/GM, comunicando su decisión de resolver el Contrato № 064-2021- MDK-GM/LOG en forma total, por la supuesta causal de incumplimiento de obligaciones contractuales, lo que considera que contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, al trasgredir la forma y fondo de la resolución contractual allí establecida. Es decir que en el presente caso no existió coherencia entre lo requerido y lo resuelto, al no cumplir con identificar cuáles son las obligaciones supuestamente incumplidas ni guardar relación con el apercibimiento realizado por la Entidad, por lo que ésta deberá ser considerada como inválida e ineficaz.

<u>Posición de la Entidad.</u>

39. A contestar la demanda la Municipalidad niega haber incumplido el ordenamiento legal, señala que previa a la comunicación de la carta resolutoria contenida en la Carta № 027-2022-MDK/GM, se remitió al Contratista la Carta Notarial № 07-2022, del 16 de mayo del 2022, donde se le requirió el cumplimiento de obligaciones contractuales, indicando expresamente "la ausencia de personal profesional técnico propuesto", misiva que fue notificada válidamente el 17 de mayo del 2022

por notario público adjuntando 30 folios y conteniendo el Informe № 685-2022-MDK/G/OGSEI/MPM-D y anexos, indicando además el apercibimiento de resolución de contrato, cumpliendo cabalmente lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, siendo falso lo afirmado por su contraria de haber incumplido el procedimiento de resolución contractual, pues en la propia carta notarial se indica expresamente la constatación de ausencia de personal técnico propuesto por la supervisión, requiriendo el cumplimiento de su obligación contractual.

40. Agregan que la segunda cláusula del Contrato establece las obligaciones del supervisor entre ellas consta la de "cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos" para lo cual el Demandante acreditó como personal clave de su oferta a los señores Samer Janampa Patilla y Oliver Sosa Oriundo.

41. Sostiene que se hicieron visitas constatando la ausencia del Supervisor el día 02 de febrero del 2022, el 09 de febrero del 2022 se constató la ausencia del personal clave, propuesto por el Contratista, el 25 de abril del 2022 se constató la ausencia del Supervisor y de su plantel técnico, lo que quedó anotado en el Acta de Constatación de fecha 25 de abril del 2022, reafirmando que la observación de ausencia de personal fue consignada en las actas de constatación y en el Informe № 685-2022-MDK/GMOGSEI/MPM-D, que obran como medio de prueba.

42. Agrega que las anotaciones de Cuaderno de Obra ofrecidas por el Demandante, no corresponden a las fechas en las que se constató la ausencia del personal profesional, sino se refiere a oportunidades distintas, remarcando que el requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales fue el 17 de mayo del 2022, y las anotaciones son del 18, 21 y 24 de mayo del 2022.

43. Posteriormente, con escrito del 10 de abril 2023 remitió documentos que señalaban y probarían otras ausencias de la supervisión

1.- Acta de verificación de fecha 17 de mayo del 2022.

2.- Acta de verificación de fecha 20 de mayo del 2022.

3.- Acta de verificación de fecha 23 de mayo del 2022.

4.- Acta de verificación de fecha 25 de mayo del 2022.

5.- Acta de verificación de fecha 26 de mayo del 2022 y acta de Juez de Paz.

6.- Acta de verificación de fecha 31 de mayo del 2022.

44. En cuanto a la carta de resolución contractual menciona que con Informe № 897-2022-MDK/GM/OSGEI/MPM-D, del 02 de junio del 2022, la Dirección General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, solicitó la resolución contractual del Contrato debido a que no se había revertido el incumplimiento de las obligaciones contractuales, en razón de ello les fue remitida la Carta Notarial № 027-2022-MDK-GM, del 08 de junio del2022, cumpliendo fielmente lo dispuesto en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Posición del Árbitro Único

45. Conforme se tiene de los actuados arbitrales, luego de que el Contratista ganara la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada № 47-2021-MDK/CS-1, con fecha 14 de diciembre del 2021, las partes hoy en controversia suscribieron el Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, cuya cláusula segunda, señalaba que el objeto de la prestación era la supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Través de Pistas y Veredas en los Sectores de Huarmamayo, Villa Pasarella y Agua Viva de la Capital del Distrito de Kimbiri, La Convención – Cusco", detallando además las funciones y obligaciones del supervisor e identificando a los profesionales que asumirían la condición de profesional clave.

46. Las Cláusulas tercera, cuarta y quinta del Contrato indicaban que el monto contractual de la contraprestación era la suma de S/ 103,348.32, siendo el plazo contractual de 210 días calendario, el cual se desarrollaría bajo la modalidad del esquema Mixto de Tarifas y suma alzada.

47. Como quiera que la controversia versa sobre resolución contractual es conveniente que se describa someramente el marco legal del mismo.

48. Se debe tener en cuenta que, una vez perfeccionado el contrato, el deudor se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de su acreedor, mientras que esta última se compromete a pagar o cumplir con la contraprestación acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten las prestaciones a su cargo con entera satisfacción de sus respectivas contrapartes.

49. Ahora bien, *"el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual pues alguna de las partes podría verse imposibilitada de cumplirlas, o hacer el incumplimiento defectuosamente"*[2]. Lo que puede provocar su resolución.

[2] OPINIÓN Técnica de OSCE № 086-2018/DTN de fecha 10 de julio de 2018.

50. Sobre *este* punto, De la Puente y Lavalle menciona que *"la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones"*[3].

51. Por su *parte*, García de Enterría señala que la resolución *"es una forma de extinción anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la conducta de la otra parte"*[4].

52. Ahora, dentro de esta categoría jurídica genérica de la resolución contractual, se encuentra la resolución por incumplimiento, que implica extinguir el vínculo contractual debido a que una de las partes no ha cumplido con la prestación a su cargo. Por ello la resolución de contrato constituye un remedio que puede ser utilizado por el acreedor frente al incumplimiento de obligaciones del deudor.

53. Por otro lado, conviene precisar que, en el presente caso, para que el contrato quede resuelto el acreedor deberá seguir el procedimiento resolutorio previsto en el contrato o, en su caso, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

54. Entonces, el Árbitro Único considera pertinente referiste a los efectos de la resolución de contrato:

    - Efecto liberatorio: La resolución extingue el vínculo contractual y, como consecuencia de ello, las partes quedan liberadas de ejecutar las prestaciones a su cargo.
    - Efecto restitutorio: Como regla general, las partes deben restituirse recíprocamente las prestaciones ejecutadas.
    - Efecto resarcitorio: A la parte perjudicada con el incumplimiento que motiva la resolución contractual le asiste el derecho de accionar en contra de la otra por los daños y perjuicios que haya podido padecer a causa de dicho incumplimiento.

    Es bajo este marco conceptual que se analizará la resolución de contrato efectuada por la Municipalidad a fin de determinar si es inválida y/o ineficaz.

---

[3] DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. *El contrato en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil*, Tomo I, Lima: Palestra, 2001, pág. 455.

[4] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. *Curso de Derecho Administrativo I,* 2001, Madrid: Civitas, 2001, pág. 750.

55. La controversia se encuentra relacionada con la resolución del Contrato efectuada por la Municipalidad, por lo cual el Árbitro Único considera importante referirse a las causales y al procedimiento de resolución previstos en el Contrato.

56. Debemos tener presente que la finalidad de la contratación pública es maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten de manera que permitan el cumplimiento de los fines públicos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, por ello conviene precisar que esta figura jurídica es un remedio tan radical y extremo que solamente es justificado cuando el incumplimiento que sufre una parte es grave o esencial, sin posibilidad de remediar dicha situación.[5]

57. La cláusula décimo tercera del Contrato, sobre resolución contractual se sustenta en el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y establece:

> **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**
> Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

58. En efecto, el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, se encuentra referido a la resolución de los contratos, el mismo que citamos a continuación:

> *"Artículo 36. Resolución de los contratos*
>
> *36.1* ***Cualquiera de las partes puede resolver el contrato,*** *por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato,* ***por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento,*** *o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. (…)".* (El énfasis agregado es nuestro)

59. De acuerdo con la norma citada, se puede resolver el contrato por tres situaciones determinantes:

- Caso fortuito o fuerza mayor.
- Incumplimiento de obligaciones regulado en el Reglamento.
- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y no imputable a las partes.

[5] Artículo 1 de la Ley 30225

60. En esa misma línea los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado regula las causales resolutorias y el procedimiento correspondiente, los que se citan:

"Artículo 164.- Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

a). ***Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello****; (el énfasis es nuestro)*

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

c). Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. (…)

164.2 El contratista puede solicitar la resolución en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165. (…)

Artículo 165.- Procedimiento de resolución de contrato

165.1Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

165.2Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

165.3Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. *(el énfasis es nuestro)*

165.4 La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea

separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total. (…)

61. De acuerdo al Reglamento, queda claro que la Entidad puede resolver el Contrato en los casos en que el Demandante: (i) incumpla de forma injustificada sus obligaciones contractuales, (ii) haya acumulado el máximo de penalidad, o (iii) paralice o reduzca la ejecución de la prestación sin justificación alguna.

    Por otro lado, el Contratista puede resolver el Contrato cuando la Entidad incumpla de forma injustificada con el pago u otras obligaciones esenciales.

62. Hay que tomar en cuenta que el procedimiento para la resolución contractual, se encuentra contemplado en el artículo 165 del Reglamento y tiene la siguiente forma de proceder:

    (i) La parte perjudicada debe requerir el cumplimiento de las obligaciones de su contraparte, mediante una carta notarial otorgándole un plazo de 5 a 15 días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
    (ii) Si vencido el plazo otorgado y el incumplimiento persiste, la parte perjudicada puede resolver el Contrato. Esta resolución debe ser comunicada mediante una carta notarial, luego de notificada la carta notarial el Contrato queda resuelto de pleno derecho.
    (iii) Si existiera acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o un incumplimiento no reversible, la Entidad podría resolver el contrato sin seguir el paso (i).

63. Teniendo en consideración lo desarrollado corresponderá evaluar los actuados arbitrales a fin de verificar en primer lugar si se cumplió con el procedimiento resolutorio y luego, si ello fuera así, se analizará si la causal resolutoria es válida y enmarcada en el contrato y la Ley.

64. En el presente caso, se advierte que la Municipalidad remite al Contratista la Carta Notarial № 007-2022-MDK/GM, de fecha 16 de mayo del 2022, notificada el 17 de mayo del mismo año, con asunto: Cumplimiento de obligación contractual de su oferta técnica, cuyo cuerpo se transcribe

ASUNTO : Cumplimiento de obligación contractual de su oferta técnica

Ref. : 1. Informe N° 685-2022-MDK/OGSEI/MPM-D
2. Contrato N° 064-2021-MDK-GM/LOG

Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que, el Director de la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones a través del Informe N° 685-2022-MDK/OGSEI/MPM-D, informa sobre las visitas realizadas a la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA Y AGUA VIVA DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2513150, en el cual constató la ausencia del plantel profesional técnico propuesto por parte de la supervisión PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.; por lo que, la Supervisión viene incumpliendo con sus obligaciones contractuales con la Municipalidad Distrital de Kimbiri.

Por consiguiente, conforme a lo expuesto en el fundamento precedente y el documento citado, **SE SOLICITA A SU REPRESENTADA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESENCIALES DE SU OFERTA Y DE SU RESPONSABILIDAD DERIVADO DEL CONTRATO N° 064-2021-MDK-GM/LOG, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS**, de acuerdo al numeral 165.1 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

65. Como se aprecia en la misiva, se imputa al demandante la "ausencia del plantel profesional técnico propuesto por parte de la supervisión PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES SAC. por lo que la supervisión viene incumpliendo sus obligaciones contractuales con la Municipalidad Distrital de Kimbiri" y párrafo aparte solicita el cumplimiento de las obligaciones del Contrato "BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, **EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS** CALENDARIOS", carta notarial fue remitida acompañada de 30 folios que incluía el Informe № 685-2022-MDK-OGSEI-MPM-D, emitida por la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, que sustentó al requerimiento. (el resaltado es nuestro).

66. El citado Informe № 685-2022-MDK-OGSEI-MPM-D tenía el siguiente asunto

ASUNTO : REQUERIR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION CONTRACTUAL DE SU OFERTA TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD DERIVADO DEL CONTRATO, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Menciona que, desde el 02 de febrero del 2022 hasta el 11 de mayo del mismo año, diversos funcionarios de la Municipalidad y autoridades de la localidad, realizaron

visitas al lugar de la obra y constataron la ausencia del supervisor y/o su asistente técnico conforme al siguiente detalle:

IV.ANALISIS

- En la visita del acta realizado el 02 de febrero del 2022, se constató la ausencia total por parte de la supervisión de la obra.

- En la visita del acta realizado el 09 de febrero del 2022, se constató la ausencia del personal clave propuesto por parte de la supervisión.

- En el Acta de constatación de la obra de la referencia realizado el día 25 de abril del 2022, se constató la ausencia del Supervisor de Obra y su plantel técnico propuesto. Así mismo, los trabajadores de la obra manifestaron sobre el retraso del pago de salarios del mes de marzo que hasta la fecha no se realizó por parte del contratista.

- En el acta de visita inopinada realizado el 25 de abril del 2022; se constató la ausencia del plantel técnico de la Supervisión de obra PICE SAC.

- En el acta de visita inopinada realizado el 29 de abril del 2022; se constató la ausencia del plantel técnico de la Supervisión de obra PICE SAC

- En el Acta de constatación de la obra de la referencia realizado el día 11 de mayo del 2022, se constató la ausencia del Supervisor de Obra y su plantel técnico propuesto. Así mismo, los trabajadores de la obra manifestaron sobre el retraso del pago de salarios por parte del contratista.

67. Nótese que conforme a lo expresado los días 02 de febrero, 09 de febrero, 25 de abril, 29 de abril y 11 de mayo del 2022 la supervisión o su plantel técnico estaba ausente de la obra. Agrega el Informe que el plantel técnico está considerado e identificado en la cláusula segunda del contrato y, al estar ausentes, se estaría "vulnerando las funciones del supervisor de acuerdo a la cláusula segunda del Contrato y detalla entre otros:

- Con la ausencia de **Supervisor de obra**, se viene vulnerando las funciones del supervisor de acuerdo a la **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO** del contrato donde menciona:

  FUNCIONES DEL SUPERVISOR

  1. Controlar los trabajos efectuados por el contratista.
  2. Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de la obra.

68. El Contratista presenta su descargo mediante su Carta Notarial № 060-2022-PICE SAC/GG fechada y entregada el 26 de mayo del 2022, en dicha carta replican el incumplimiento imputado, aclarando el detalle de la hora de ocurrencia, tal como se aprecia

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. Con fecha **02/02/22** se realiza una visita a obra por parte de los funcionarios de la Entidad entre las 11:50am a 12:43pm, suscribiendo una Acta luego de su visita de 53 minutos.
2. Con fecha **09/02/22** se realiza una visita a obra por parte de los funcionarios de la Entidad entre las 09:40am a 11:20pm, suscribiendo una Acta luego de su visita de 1 hora y 40 minutos.
3. Con fecha **25/04/22** se realiza una visita a obra por parte de los funcionarios de la Entidad entre las 04:04pm a 05:00pm (término de jornada), suscribiendo una Acta luego de su visita de 56 minutos.
4. Con fecha **29/04/22** se realiza una visita a obra por parte de los funcionarios de la Entidad entre las 11:30pm a 12:00pm (horario de descanso y almuerzo en obra), suscribiendo una Acta luego de su visita de 30 minutos.
5. Con fecha **11/05/22** se realiza una visita a obra por parte de los funcionarios de la Entidad entre las 08:45pm a 12:27pm, suscribiendo una Acta luego de su visita de 3 horas y 42 minutos.

En todas las visitas realizadas por los tiempos descritos, el funcionario concluye que no hay presencia del personal clave de la supervisión.

indican que vienen cumpliendo con las obligaciones que le competen como supervisión lo que se acredita con los asientos en el cuaderno de obra y las acciones ejecutadas,

lo cual es totalmente incoherente, debido a que si el supervisor no cumpliese con sus funciones, no podría llevarse a cabo ninguno de los puntos señalados en la imagen extraída del contrato mencionado, para lo cual lo refutamos con todas las acciones que viene realizando el supervisor de obra, las mismas que se reflejan en los asientos del cuaderno de obra, en los informes remitidos sobre cada consulta y/o trámite necesario que requiera de su opinión, en su constante seguimiento al cumplimiento

Agregando que la ausencia del personal clave no está considerado como obligación del Contratista, al no estar incorporada en la cláusula segunda del Contrato que detalla las funciones y obligaciones del supervisor, y que por su ausencia (que no niegan) corresponde aplicar penalidades, y tal hecho se encuentra expresamente considerado en la Cláusula Duodécima del Contrato, que trataba las penalidades e indicaba:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Por ausencia (según cronograma de ejecución de obra) del Supervisor de obra de la propuesta técnica en el lugar de emplazamiento del proyecto	0.1% de 1 UIT por día de ausencia del profesional	Según informe del jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones

En ese sentido, continúa la carta, no se ha incumplido ninguna obligación comprendida y detallada en la cláusula segunda del Contrato, y en todo caso la resolución operaría después de la acumulación de penalidades por un monto superior al 10% del total del Contrato.

69. Recibido el Descargo la Entidad procedió a evaluarlo y determinó que el incumplimiento continuaba en razón de lo cual procedió a remitir al Demandante la Carta Notarial № 027-2022-MDK/GM de fecha 08 de junio del 2022, mediante la cual le comunicó su decisión de resolver el Contrato, tal como se muestra en la impresión.

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Kimbiri, 08 de junio del 2022

COLEGIO NOTARIAL AYACUCHO

CARTA NOTARIAL Nº 027-2022-MDK/GM

SEÑOR:
PERCY LÓPEZ FLORES
Representante Legal de la Empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.
Dirección: Av. Aeropuerto N° 224, Distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco
Correo: pice_sac@hotmail.com
Celular: 966635454

ASUNTO : **COMUNICO RESOLUCIÓN TOTAL DE CONTRATO**

Ref. : **1.** Informe N° 199-2022-MDK/OGAJ/UGAP
2. Informe N° 897-2022-MDK/GM/OGSEI/MPM-D
3. Carta Notarial N° 007-2022-MDK/GM
4. Contrato N° 064-2021-MDK-GM/LOG

.....

Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que habiendo agotado previamente las vías de comunicación mediante Carta Notarial N° 007-2022-2022-MDK/GM, notificado notarialmente el 17.05.2022, con la cual se solicitó a su representada **EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESENCIALES DE SU OFERTA Y DE SU RESPONSABILIDAD DERIVADO DEL CONTRATO N° 064-2021-MDK-GM/LOG, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS**; sin embargo, pese habérselo solicitado, no se ha revertido el incumplimiento, por tanto, **en el marco del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cumplimos con informarle que, procedemos a resolver el Contrato N° 064-2021-MDK-GM/LOG, suscrito con fecha 14.12.2021**.

70. De lo expuesto se infiere que la Entidad Demandada si ha cumplido con indicar en su carta notarial lo que consideraba incumplimiento contractual, permitiendo a su contraparte conocer perfectamente el detalle del incumplimiento que le imputaba: la ausencia del personal clave propuesto en la oferta técnica y señalado en el

Contrato. En consecuencia, el Árbitro Único considera que el procedimiento de resolución contractual efectuado por la Municipalidad se ajusta a lo regulado en el Reglamento, teniendo en consideración la causal alegada.

71. Estando a lo expuesto, corresponde que el Árbitro Único analice la causal esgrimida por la Entidad a fin de verificar si la misma se encuentra dentro de los supuestos resolutorios señalados en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

72. Sobre el particular se observa que la Entidad imputa al Contratista el incumplimiento contractual consistente en la ausencia del personal profesional clave como es el supervisor y el asistente de supervisor.

73. Como quiera que la resolución versa sobre la causal de incumplimiento contractual es conveniente definir su concepto y sus diversas aplicaciones

74. Según la Real Academia de la Lengua al Incumplimiento Contractual vendría a ser la vulneración de lo estipulado en un contrato por una o ambas partes; por ello se puede definir al incumplimiento como la causa de acción legal en donde un acuerdo vinculante o un intercambio negociado no es respetado por una o más de las partes del contrato por mal desempeño, demora o interferencia con el desempeño de las otra parte.

75. El incumplimiento consiste pues en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío. Se debe prestar especial atención a dos características de la definición. La primera es que la definición de “incumplimiento” incluye tanto las de incumplimiento total, como aquellas referidas a cumplimiento defectuoso o tardío, o e general a cualquier defecto en la ejecución de la prestación.

76. La Cláusula Segunda del Contrato detalla las funciones y obligaciones que el del Supervisor se compromete a cumplir en la ejecución de su prestación, tal como se trascribe:

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

1. *Controlar los trabajos efectuados por el contratista.*
2. *Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de la obra.*
3. *Velar el cumplimiento del contrato del contratista de obra.*
4. *Controlar la ejecución de la obra.*
5. *Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de obra, de acuerdo a los plazos establecidos.*
6. *Está facultado para ordenar el reitero de cualquier trabajo, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.*
7. *Está facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.*
8. *Está facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que pongan en peligro y/o riesgo de la vida de personas, la prioridad pública o privada, por la obra en ejecución, que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.*
9. *Su actuación y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión y/o de ejecución de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones señaladas en las Bases y el Reglamento de Contrataciones del Estado.*
10. *Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.*
11. *Firmar en todas sus páginas del cuaderno de obra y abrir y/o aperturar el cuaderno de obra en la fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con el residente de Obra, siendo los únicos profesionales responsables para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, correspondiéndole al supervisor.*
12. *Contralar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contratista, así como el aporte de contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, etc. Así como el pago de servicios y beneficios sociales del personal profesional técnico-Administrativo y obrero relacionado a la obra.*

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusión de las obligaciones, por la supervisión de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

- ✓ *Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad sobre su observación y/o conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o Proyectista del expediente técnico.*
- ✓ *Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, así como las probables modificaciones y/o reformuladas del expediente de obra, presupuestos adicionales y deductivas de la obra.*
- ✓ *Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el proyecto durante la ejecución de la Obra.*
- ✓ *Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos e informar a la Entidad en forma mensual.*
- ✓ *Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra, presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) días de anticipación al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad procederá a la ejecución de las cartas fianzas en cumplimiento a la normatividad vigente.*
- ✓ *Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentarias vigente.*
- ✓ *Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas.*
- ✓ *Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medición en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances físicas y financieros de obra, mediante la utilización de programas de computación.*
- ✓ *Vigilar y hacer que el residente de la obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como el personal involucrado en la obra, que deberán reflejarse en la toma fotográfica respectiva.*
- ✓ *Inspección y verificación permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos utilizados en obra, así como el control físico de los mismos, presentado en los informes mensuales correspondiente, su inventario detallado y actualizado, debiendo además llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias según propuesta técnica del Contratista.*
- ✓ *Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.*

- ✓ *Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; caso necesario tomar las previsiones proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.*
- ✓ *Durante la etapa de inicio de obra, en plena ejecución de obra y en la recepción de obra, el supervisor tomara en cuenta la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.*
- ✓ *Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles fotográficos en general de obra.*
- ✓ *Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.*
- ✓ *Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad, que rige los contratos y directivas de la Entidad.*
- ✓ *Efectuar la verificación de los trabajos, para la recepción de la obra e informar sobre la solicitud de la recepción de la obra, presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista, es exacta en cuanto a la culminación de la obra.*
- ✓ *Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecución de obra.*
- ✓ *Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.*
- ✓ *Suscribir el acta de observaciones y recepción de obra, en calidad de miembro (Asesor) del comité de recepción.*
- ✓ *Revisar y aprobar la liquidación final de obra, que presente el Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.*
- ✓ *Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias y otros ofertados.*
- ✓ *Compromiso de carácter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentación de obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorización previa de la Entidad.*
- ✓ *Efectuar la verificación para el pase de la primera valorización que el Contratista cumpla con presentar la copia del extracto de presentaciones y pago expedida por la SUNAT, copia de inscripción de la obra en el ministerio de trabajo.*
- ✓ *A partir de la segunda valorización presentada copia del extracto de presentaciones y pagos expedidos por la SUNAT, así como el aporte de contribuciones y beneficios sociales, del mes anterior al que corresponda la valorización.*
- ✓ *Así mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la valorización final, el contratista deberá presentar una constancia y/o certificado de NO Adeudos por ningún concepto, otorgado por la autoridad competente y/o Juez de Paz, del lugar donde se ejecuta la obra.*

Detallándose en la misma cláusula, el nombre de los profesionales que integrarían el plantel profesional clave:

EL CONTRATISTA contará con el siguiente plantel **profesional clave**, conforme a su oferta técnica:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	PROFESIÓN	N° COLEGIATURA
SAMER JANAMPA PATILLA	SUPERVISOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	76363
OLIVER SOSA ORIUNDO	ASISTENTE TÉCNICO DE SUPERVISIÓN	INGENIERO CIVIL	203617

77. Fluye de lo expresado que los fines y obligaciones contractuales que PER & INGENIEROS Y CONSULTORES SAC. tenía como obligación contractual desarrollar todas las actividades mencionadas líneas arriba, para lo cual se contaba con la presencia de los profesionales propuestos, y, si bien no se expresa de manera específica la obligación de su permanencia física del personal profesional clave, si consta su función de "velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra"; [6]

78. Hay que tomar en cuenta que la prestación se realizaría a través de la intervención directa y personal del ingeniero supervisor de obra y del ingeniero asistente técnico de supervisión, para ello era necesaria su presencia en el lugar de ejecución de la obra Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Través de Pistas y Veredas en los Sectores de Huarmamayo, Villa Pasarella y Agua Viva de la Capital del Distrito de Kimbiri, La Convención Cusco, que supervisan. Es decir que la presencia de estos profesionales era necesaria para cumplir el objeto de la contratación.

79. No obstante, lo expresado también se aprecia que la Cláusula Duodécima del Contrato contiene una Cláusula Penal.

80. Se debe tener presente que la cláusula penal es la estipulación en un contrato que se refiere a la sanción específica para el caso de incumplimiento contractual concreto. Es obvio, por lo demás, que cuando las partes acuerden la sanción a un hecho específico, lo harán a través de una cláusula en la que se refieran a ella, independientemente de si dicha cláusula solo aluda a tal penalidad o si incluye, además, disposiciones de otra naturaleza. Más allá de esas consideraciones, la cláusula penal, a grandes rasgos, puede definirse como un "pacto anticipado de indemnización por un incumplimiento contractual específico. En ella se dispone que, si el deudor incurre en el hecho sancionado, tendrá que pagar una indemnización de daños y perjuicios, cuyo monto también se especifica en el pacto."[7]

81. Siguiendo a los mismos autores, debemos subrayar que la cláusula penal, al igual que los daños y perjuicios, puede tener naturaleza moratoria o compensatoria, dependiendo de si con ella se busca indemnizar la mora en el pago o si lo que se pretende indemnizar es el cumplimiento parcial o defectuoso o el incumplimiento definitivo de la obligación.

---

[6] Véase la Función 2) de la cláusula segunda del Contrato

[7] La Cláusula Penal, Los Contratos, Consecuencias Jurídicas de su Incumplimiento, Felipe de Osterling y otros autores, Ediciones Gaceta 1º Ed. junio 2013, pág. 10

82. Apreciamos pues que la cláusula penal grava un incumplimiento contractual específico, cuyas consecuencias reparatorias se encuentran tasadas.

83. El Capítulo IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones regula el Incumplimiento Contractual, allí se aprecia el artículo 161 que dispone la aplicación de penalidades al contratista ante incumplimiento injustificado de sus obligaciones, sean estas por mora u otras aplicables, disponiendo:

"Artículo 161. Penalidades

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse" (… …)

84. El artículo 162 de la misma norma detalla la aplicación de la penalidad por mora y dispone:

Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones *objeto* del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: (… …)

85. En la misma línea el artículo 163 del Reglamento permite la aplicación de penalidades distintas a la mora:

"Artículo *163. Otras penalidades*

163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar."

"163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora."

86. En mérito a las normas citadas se aprecia que el Contrato también contiene cláusulas penales, en donde su Cláusula Duodécima describe su aplicación frente a dos tipos de incumplimiento, en primer lugar, referidos a la mora acordando:

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

87. La cláusula incluye además penalidades por incumplimiento defectuoso, entre los que se señala específicamente la ausencia del supervisor de obra de la propuesta técnica en el lugar de emplazamiento del proyecto, tal como se aprecia de la citada cláusula:

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Por ausencia (según cronograma de ejecución de obra) del Supervisor de obra de la propuesta técnica en el lugar de emplazamiento del proyecto.	0.1% de 1 UIT por día de ausencia del profesional.	Según informe del jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones.

88. De lo que se infiere que la voluntad contractual de las partes era aplicar la sanción específica frente a un incumplimiento contractual concreto, primando el acuerdo específico frente al general, máxime cuando al tener una compensación prevista pierde su condición de causa resolutoria.

89. Por consiguiente, al incurrir el Contratista en ausencia en obra del Supervisor, correspondía se aplique una penalidad consistente en 0.1% de la UIT por cada día de ausencia del profesional, deducido de los pagos a cuenta, valorizaciones, pago final o liquidación final, según corresponda;[8] para la aplicación de penalidad el procedimiento fijado es el informe verificador del Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones de la Entidad, de lo que se infiere que este incumplimiento específico no está comprendido dentro del incumplimiento contractual general materia del artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

[8] Artículo 161.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

90. Por tanto, estando el Contratista incurso en el incumplimiento contractual comprendido dentro de la aplicación de penalidades, correspondía su aplicación conforme a la Cláusula Duodécima, y no la resolución contractual por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales reglado por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y la Cláusula Décimo tercera del Contrato, por consiguiente corresponde acoger el presente punto controvertido, declarando la invalidez e ineficacia de la resolución contractual efectuada por la Municipalidad y contenida en la Carta Notarial № 027-2022-MDK/GM.

SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal declare la validez y eficacia de la resolución del Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, efectuado por la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C, mediante Carta Notarial № 003-2022-PICE.SAC/GG

<u>Posición del Demandante</u>

91. El Contratista sostiene que la ejecución del Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, se inició en enero del 2022, y ellos venían cumpliendo su prestación de manera diligente controlando de manera directa y permanente la ejecución de la obra, en consecuencia, correspondía a la Entidad el pago de las valorizaciones presentadas oportunamente y dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

92. Así, es de ver que con carta № 050-2022-PICE.SAC/GG, presentado a la Entidad el 06 de mayo de 2022, presentaron la valorización correspondiente al mes de abril de 2022, por la suma total de S/ 11,466.06, que fuera observada por el área usuaria de la Municipalidad; como consecuencia de ello, mediante Carta № 067-2022-PICE.SAC/GG, del 31 de mayo de 2022, se cumplió con levantar las observaciones advertidas, por tanto les correspondía cumplir con el pago, lo que no ha ocurrido hasta la fecha de interposición de la demanda.

93. Con carta № 073-2022-PICE.SAC/GG, de fecha 06 de junio de 2022, cumplieron con presentar la valorización correspondiente al mes de mayo de 2022, por el importe de S/ 14,518.09, el cual fue calculado de acuerdo a la tarifa de referencia unitaria fijada en el contrato. Dicha valorización no fue observada por la Demandada, por lo que presumen su aprobación y tiene derecho al pago correspondiente; sin embargo, a la interposición de la demanda no cumplieron con ello.

94. Asimismo, mediante Carta № 077-2022-PICE.SAC/GG, de fecha 20 de junio del 2022, presentaron la valorización correspondiente al mes de junio (del 01 al 10 de junio de 2022), por el monto ascendente a S/ 4,683.25. Dicha valorización fue

realizada a esa fecha debido a que la Entidad les resolvió el contrato de supervisión indebidamente.

95. Considerando el derecho al pago que les asiste por la prestación efectiva del servicio de supervisión a favor la Entidad, es que mediante Carta Notarial № 002-2022-PICE.SAC/GG, requirieron a la Entidad cumpla con la obligación esencial de pago bajo apercibimiento de resolverse el contrato, para tal fin, otorgaron el plazo de tres días calendarios el cual venció sin recibir su contraprestación, en consecuencia les remitieron la Carta Notarial № 003-2022-PICE.SAC/GG, notificada el 25 de agosto de 2022, haciendo efectiva la resolución de Contrato por la causal de incumplimiento injustificado de obligación esencial de la Entidad, quedando resuelto el contrato de pleno derecho.

96. Agregan que el plazo para que la Demandada inicie algún mecanismo promoviendo controversia, sea conciliación y/o arbitraje, venció el 11 de octubre del 2022 sin que se promoviera controversia por tanto su resolución quedó consentida.

Posición del Demandado

97. La Municipalidad contesta la demanda y sobre este punto manifiesta que las cartas solicitando el pago de las valorizaciones fueron presentadas "después de haberse requerido el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la Entidad y posterior a la resolución del Contrato realizada por la Entidad plasmada con Carta Notarial № 007-2022-MDK/GM.

98. Agrega que las valorizaciones son pasibles de ser observadas por la Municipalidad, lo que demanda un tiempo prudencial para ser evaluadas por el área técnica de la Entidad.

99. Así mismo observa que las cartas notariales de requerimiento de pago de valorizaciones y posterior resolución contractual se efectuaron en agosto del 2022, cuando ya el Contrato se encontraba resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de la comunicación resolutoria efectuada por la Municipalidad efectuada el 08 de junio del 2022, no existiendo más obligaciones contractuales entre las partes, por lo que la Contratista no se encontraba facultada legalmente para resolver el contrato cualquiera sea la causa.

Posición del Árbitro Único

100. En Principio se debe tener presente que, en efecto, el artículo 165.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones señala desde cuando opera la vigencia de la resolución contractual y señala:

> "Artículo 165. Procedimiento de Resolución de contrato
>
> (...)

165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. **El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación."** (… …) (el énfasis es nuestro)

101. También es no menos cierto que el artículo 166 de la misma norma regula los efectos de la resolución y dispone:

"Artículo 166. Efectos de la Resolución

(…)

166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo **sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida** (el énfasis es nuestro)

102. Por consiguiente, estando a las normas indicadas se aprecia que si bien la resolución contractual surte efectos a partir de la recepción de la comunicación resolutoria, será eficaz y surtirá efectos siempre y cuando dicha resolución haya quedado consentida, y esto sólo sucederá si no se ha promovido controversia dentro del plazo de caducidad señalado en la norma, o si luego de promovida, la controversia ha sido declarada válida o firme.

103. Si acaso la resolución contractual fuese declarada, nula, invalida y/o ineficaz significará que la misma no fue emitida siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos y formalidades previstas en la normativa de contrataciones del Estado, esto es que no se cumplió el procedimiento o que la causal invocada no se ajusta a Ley.

104. Como quiera que la resolución contractual promovida por la Entidad ha sido considerada inválida y sin efecto alguno, corresponderá analizar si el procedimiento seguido por el Contratista contra la Entidad se adecúa a lo estipulado en la normativa de contrataciones ya citada.

105. Así se aprecia que mediante Carta Notarial № Carta Notarial № 002-2022-PICE.SAC/GG, el Contratista requiere a la Entidad para que en el plazo de tres días calendarios cumpla con pagarles los importes correspondientes **a 3 valorizaciones consecutivas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del 2022**, las mismas que en su momento fueron puestas a su conocimiento para el pago, conforme al siguiente detalle:

- Cartas №s 050-22-PICE.SAC/GG del 06 de abril del 2022 y 067-2022-PICE.SAC/GG, de fecha 31 de mayo correspondiente a la valorización del mes de abril del 2022, por S/. 11,466.06.
- Carta № 073-2022-PICE.SAC/GG, del 06 de junio del 2022, correspondiente al mes de mayo del 2022, por S/. 14,518.09 y
- Carta № 077-2022-PICE.SAC/GG, del 20 de junio del 2022, correspondiente al mes de junio del 2022 (del 01 al 10 del mismo mes por la resolución contractual promovida de la Entidad) por S/.4,683.25.

Dejando constancia que la Entidad no se ha negado ni opuesto a la existencia de tales obligaciones.

106. Vencido el plazo otorgado sin recibir el pago, el demandante remitió a la Municipalidad la Carta Notarial № 003-2022-PICE.SAC/GG, notificada el 25 de agosto del 2022, haciendo efectivo el apercibimiento y resolviendo el Contrato por la causal de incumplimiento injustificado de la obligación esencial de pago.

107. De lo actuado se acredita que el Contratista cumplió con el procedimiento resolutorio establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, y la causal invocada se encuentra contenida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

108. El numeral 166 del ya citado reglamento, establece los efectos de la resolución e incluso señala los términos para accionar en contra de ella y dispone:

"Artículo 166. Efectos de la resolución

(…)

166.3 Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. ***Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida."*** (énfasis agregado)

109. El plazo antes indicado es de caducidad, tal como determinan los artículos 45.5 y 45.9 de la Ley de Contrataciones, como se transcribe a continuación:

Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual

(…)

45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o

metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio reglamento. de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

(…)

45.9 Todos los plazos señalados en los numerales precedentes son de caducidad".

110. La Entidad no ha manifestado haber promovido controversia contra la resolución contractual recibida; mencionando que mediante Carta № 550-2022-MDK/GM del 26 de agosto del 2022 rechazó lo afirmado en la carta resolutoria, sin tener en cuenta que los efectos de la resolución sólo operan desde que ésta quede consentida, y existiendo una controversia la validez de su decisión estaba en suspenso.

111. En ese sentido se puede concluir que al no haber promovido controversia contra la resolución contractual contenida en la Carta Notarial № 003-2022-PICE.SAC/GG, notificada el 25 de agosto del 2022, la resolución contractual promovida por el Contratista quedó consentida y por tanto el Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG resuelto de pleno derecho a partir de dicha comunicación.

112. No obstante, lo determinado, el Árbitro Único hace un somero análisis sobre la causal invocada por el Contratista. En efecto, el artículo 164.2 del Reglamento le faculta a resolver el contrato cuando la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, conforme al procedimiento ya detallado.

113. Por su parte el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones regulan la forma de pago de las prestaciones, las que no quedan al albedrío de la Entidad, sino que deben sujetarse a la ley y al Contrato cuya Cláusula Cuarta, establecía un plazo para otorgar la conformidad a las valorizaciones, tal como se lee del extracto:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

No obstante, lo determinado, la Entidad, no ha probado justificación alguna que impida su pago oportuno, por lo que se infiere que incumplió injustificadamente con dichos pagos,

114. A más abundar la Dirección Técnico Normativa del OSCE, a indicado que la omisión al pago de tres valorizaciones consecutivas amerita activar la causal de incumplimiento en el pago, en razón de lo expuesto corresponderá amparar el punto controvertido.

TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Kimbiri, el pago por concepto de indemnización de daños y perjuicios, a favor de la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C

Posición del Demandante

115. El Contratista solicita que la Municipalidad Distrital de Kimbiri asuma la indemnización de daños y perjuicios que le corresponde, cuyo importe sería debidamente cuantificado oportunamente, ello en mérito a lo dispuesto en el artículo 166.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que le reconoce este derecho al haberse consentido la resolución del contrato por causas imputables a la Entidad.

116. El Árbitro Único deja constancia que fuera de lo expresado, el Contratista no esgrime ningún argumento sustentatorio ni ofrece prueba en defensa de su alegación, limitándose a afirmar que ofrecerá un informe pericial a fin de cuantificar y sustentarla.

Posición de la Municipalidad

117. La Entidad manifiesta que la imputación de resolución es al Contratista por haber incumplido obligaciones contractuales, no pudiendo atribuírseles causal resolutoria pues el procedimiento de resolución iniciado por el Contratista se efectuó cuando ya no existía relación contractual con el Demandante.

118. Agrega que la pretensión indemnizatoria no indica monto, por lo que no resulta cuantificable, limitando se derecho a la defensa a fin de refutar dicho monto.

119. Concluye indicando que la pretensión indemnizatoria no acredita los elementos constitutivos para la reparación civil.

Posición del Árbitro Único

120. Tal como se dejó constancia líneas arriba, el Demandante no sustenta su pretensión ni ofreció medio probatorio respecto a éste punto controvertido; en ese

orden de ideas se debe tener presente que la finalidad del proceso es la solución de controversias, eliminando la incertidumbre existente entre ellas.[9]

En ese sentido se debe tener presente que, el ya citado Principio del *Onus Probandi Incumbit Actori*, le otorga al actor la responsabilidad de probar los hechos que configuran su pretensión.

121. Es importante que, tal como acertadamente lo describe Ledesma "el proceso debe responder a un leal debate procesal en el que se expresen en forma clara y enumerada los hechos del conflicto a fin de evitar emboscadas posteriores del adversario. Se busca dar moralidad al proceso al incorporar en el ordenamiento procesal estructuras normativas con contenido ético, pues la conducta del justiciable no puede ser indiferente al derecho procesal. [10]

122. Hay que tomar en cuentra que para que ello ocurra cada parte está en la obligación, y en su propio interés, que manifieste lo que convenga a su derecho, presenteando u ofreciendo las pruebas que estime conveniente, no hacerlo puede constituir un acto de mala fe procesal ya que podría realizarse con la única finalidad de entorpecer el proceso.[11]

123. En el presente punto controvertido, el Contratista simplemente se ha limitado describir su pretensión sin aportar argumento o prueba alguna que sustente su derecho, por tanto corresponderá declarar la improcedencia de su petición, no acogiendo el presente punto controvertido.

CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Kimbiri pagar las costas y costos asumidos por la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C en el presente proceso arbitral.

124. El Árbitro Único procede a emitir pronunciamiento respecto a la presente pretensión de la demanda referida a los costos arbitrales.

---

[9] Código Procesal Civil, Título Preliminar, Artículo III.- Fines del proceso e integración de la norma procesal. - El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.

[10] LEDESMA NARVÁEZ, Marianella (2008). *Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo I*. Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 420)

[11] Código Procesal Civil:
Artículo 112.- Temeridad o mala fe
Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:
1.- Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio;

125. El Árbitro Único considera conveniente precisar algunos aspectos generales referidos a los costos arbitrales dentro del proceso. En esa medida, refiere GONZÁLES DE COSÍO[12]:

> *El Código de Comercio establece expresamente la libertad de las partes de convenir el método de reglamentación de las costas del arbitraje. Esta libertad puede ser ejercida ya sea directamente (mediante pacto expreso), o indirectamente (mediante una remisión a un reglamento arbitral). Es por lo general la segunda práctica seguida.*

126. Por consiguiente, siendo que los costos arbitrales son parte de las reglas del proceso, y son las partes quienes tienen la libertad y autonomía para decidir sobre ello, será relevante en primera instancia revisar lo dispuesto en el convenio arbitral del presente proceso respecto a los costos arbitrales, y ante la ausencia de acuerdo, la Ley de Arbitraje, el Reglamento del Centro de Arbitraje.

127. Revisado el acuerdo entre las partes, se observa que el Convenio Arbitral contenido en la Cláusula Décimo Sétima del Contrato no contiene ningún acuerdo respecto a la distribución de los costos arbitrales.

128. Asimismo, el Árbitro Único considera pertinente tener presente que el artículo 56 de la Ley de Arbitraje que en el laudo el árbitro deberá pronunciarse "… sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73".

129. Por su parte, el Reglamento del Centro de Arbitraje respecto a la asunción o distribución de los costos arbitrales del proceso, en su artículo 42 ha establecido lo siguiente:

> *Artículo 52º.-*
>
> *Contenido del laudo:*
>
> *(...)*
>
> *g. La referencia sobre la asunción o distribución de los costos arbitrales.*

130. En este orden de ideas el artículo 73° de la Ley de Arbitraje refiere lo siguiente:

> *"Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.*
>
> *El Árbitro Único tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Árbitro Único*

[12] GONZÁLES DE COSÍO, Francisco. "Arbitraje". 1° Edición , Editorial Porrúa S.A., México, 2004, p. 300.

podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (…)".

131. En suma, la Ley de Arbitraje contiene un mandato imperativo que obliga al árbitro a pronunciarse respecto a la condena de costos arbitrales del proceso y la forma en que esta se distribuirá; y, el artículo antes citado que, a falta de acuerdo o pacto entre las partes respecto a la forma de asunción o distribución de los costos arbitrales en el convenio arbitral, es facultad del Árbitro Único decidir y pronunciarse sobre los costos arbitrales.

132. Por consiguiente, el Árbitro Único considera pertinente referirse al principio de vencimiento objetivo. Este principio responde a consideraciones básicas relativas a la justicia y la plena reparación: sería injusto que la víctima de un acto ilícito o injusto sea sancionada por reclamar justicia y que, al tener que pagar sus propias costas, no fuera colocada en la situación en que debería estar si el acto no se hubiera producido.

133. En otras palabras, sería injusto que un actor tuviese que soportar los gastos de un proceso que ha tenido que iniciar para ver reconocidos sus derechos, y que hasta entonces su contraparte le ha estado negando. Del mismo modo, sería injusto que un demandado quedase obligado a asumir los gastos en los que ha tenido que incurrir para defenderse de un procedimiento iniciado injustamente contra él.

134. En ese sentido, en el presente Laudo Arbitral, el Árbitro Único se pronunciará sobre los costos derivados del presente proceso arbitral, de conformidad con el Reglamento del Centro de Arbitraje y los artículos 70° y 73° de la Ley de Arbitraje.

135. En esa línea de ideas, en el presente caso el Árbitro Único, teniendo la facultad de poder resolver respecto a la distribución de los costos arbitrales, considera conveniente que el fundamento para la determinación de la asunción y distribución de los costos arbitrales se a través del principio del vencimiento objetivo. Este principio refiere que sería contrario a Derecho e ilógico que la parte que finalmente triunfa en el arbitraje asuma todo o parte de los costos.

136. En el caso concreto, el Árbitro Único advierte que las pretensiones formuladas en la demanda por el Consorcio no han sido declaradas fundadas en su totalidad, por lo que no existe una parte vencida de forma certera.

137. En consecuencia, el Árbitro Único considera que cada parte debe asumir el 50% de los costos del presente arbitraje, esto es, los gastos administrativos de la Secretaría Arbitral y los honorarios del Árbitro Único. Respecto a los costos de defensa legal y técnica incurridos por cada parte, ninguna de ellas ejerció su

derecho de pronunciarse sobre los mismos o cuantificarlos, por lo que estos deben de ser asumidos de forma individual.

138. Al respecto, el Árbitro Único tiene en consideración la liquidación provisional efectuada por el Centro Arbitral y dispuesto en Resolución № 1 donde se estableció como honorarios arbitrales la suma de S/. 4,227.01 y S/. 3,200.22 por concepto de gastos administrativos, cuyo total, ascendente a S/. 7,424.23 fue asumido por el Demandante, más los impuestos de ley, tal como se dejó constancia en las resoluciones №s 1 y 2 mencionadas líneas arriba,

139. Por consiguiente, teniendo en cuenta que el Árbitro Único determinó que cada parte asuma el 50% de los gastos administrativos del Centro de Arbitraje y los honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal, por lo tanto, la Municipalidad debe pagar o reembolsar al Contratista la suma de S/. 3,713.61 por concepto de costos arbitrales, más los impuestos de ley que haya pagado.

VIII PARTE RESOLUTIVA

140. El Árbitro Único deja constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en la Ley de Arbitraje y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

LAUDO

Estando a las consideraciones precedentes, en Derecho y dentro del plazo correspondiente, el Árbitro Único **RESUELVE:**

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la primera pretensión de la demanda y, en consecuencia, inválida e ineficaz la Resolución de Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, efectuada por la Municipalidad Distrital de Kimbiri, a través de la Carta Notarial № 027-2022-MDK/GM, de fecha 08 de junio del 2022.

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA** la segunda pretensión de la demanda y en consecuencia válida y eficacia la resolución del Contrato № 064-2021-MDK-GM/LOG, efectuado por la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C, mediante Carta Notarial № 003-2022-PICE.SAC/GG, notificada a la Municipalidad Distrital de Kimbiri el 25 de agosto del 2022.

TERCERO: Declarar **INPROCEDENTE** la tercera pretensión de la demanda, y en consecuencia no corresponde ordenar a la Municipalidad Distrital de Kimbiri, el pago

por concepto de indemnización de daños y perjuicios, a favor de la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.

CUARTO: Declarar **INFUNDADA** la cuarta pretensión de la demanda y en consecuencia no corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Kimbiri pague las costas y costos asumidos por la empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C en el presente proceso arbitral;

QUINTO: DISPONE que cada parte asuma el 50% de los gastos administrativos del Centro de Arbitraje y los honorarios del Árbitro Único, los cuales fueron asumidos en su totalidad por el Contratista, por tanto, **ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Kimbiri que pague a PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. la suma de S/. S/. 3,713.61 (tres mil setecientos trece y 61/100 soles) por concepto de reembolso de costos arbitrales, más los impuestos de ley que haya pagado.

SEXTO: ORDENA a la Municipalidad Distrital de Kimbiri que pague a PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C la suma de S/. 3,713.61 (tres mil setecientos trece y 61/100 soles) más los impuestos que haya pagado, por concepto de reembolso de gastos arbitrales asumidos por el Demandante vía subrogación.

Respecto a los gastos correspondientes a defensa legal y otros gastos incurridos por las partes, el Árbitro Único dispone que estos gastos sean asumidos de forma individual por cada parte.

QUINTO: FIJAR como honorarios definitivos del presente arbitraje los señalados en el presente laudo, conforme al artículo 70° de la Ley de Arbitraje.

El Presente laudo es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes de conformidad con el la cláusula décimo tercera del Contrato y el artículo 45.2 de la Ley de Contrataciones del Estado

MARIO EDUARDO VICENTE GONZÁLEZ PERALTA
Árbitro Único

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI
Secretaria Arbitral